

1515468-90.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Crimes contra a vida

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... in idem.

A autoria do crime acima, de tráfico, imputado ao acionado, ecoa da prova produzida, sem margem para a pretendida absolvição ou desclassificação.

No que tange, porém, ao crime de associação para o tráfico, respeitadas posições divergentes, melhor sorte não assiste à acusação.

O acusado não foi interrogado na etapa policial, em razão de ter sido internado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515468-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515468-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

GUSTAVO MARTINS foi denunciado e se vê processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 todos c.c. artigo 61, inciso II, "j", e na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, porque, (i) no dia 24 de junho de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Sebastião Gonçalves, altura do numeral 1260, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, durante conhecido estado de calamidade, trazia consigo, aproximadamente, 39g de cocaína e 5,97kg de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; (ii) em oportunidade anterior aos fatos, na Rua Sebastião Gonçalves, altura do numeral 1260, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, durante

conhecido estado de calamidade, associou-se a pelo menos mais uma pessoa, a qual até o momento não foi identificada, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes; e (iii) na mesma oportunidade, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Sebastião Gonçalves, altura do numeral 1260, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca de São Paulo – SP, durante conhecido estado de calamidade, portava arma de fogo de uso permitido, qual seja um revólver marca Taurus, calibre .32, de numeração 379250, com 5 munições íntegras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Válido registrar que a presente ação penal teve início junto à 5ª Vara do Júri da Capital, com Denúncia original (posteriormente aditada nos termos acima) oferecida às fls. 01/05, que, além de outros, imputava ao réu a prática de crime doloso contra a vida, consistente em homicídio tentado.

O réu foi citado (fls. 198), tendo apresentado Resposta Escrita à Acusação (fls. 125/135).

Em audiência, realizada pela Vara do Júri, foi colhida a prova oral e interrogado o acionado (sequência de fls. 228/229), oportunidade em que prolatada Sentença de desclassificação do crime doloso contra a vida inicialmente imputado ao acusado (fls. 230/232).

Distribuídos os autos a esta 22ª Vara Criminal Central, foi aberta vista ao Ministério Público oficiante, que promoveu o Aditamento à Denúncia, nos termos do parágrafo primeiro, acima (fls. 249/252).

Em seguida, foi oportunizada a manifestação por parte da Defesa (fls. 270), seguindo-se a decisão pelo recebimento do aditamento ministerial (fls. 271).

Ponderações finais das partes em Memoriais (Ministério Público, a fls. 282/300 e Defesa, a fls. 309/318).

Auto de Exibição e Apreensão, a fls. 22/23.

Laudo de Constatação dos Entorpecentes, a fls. 24/27.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 277/279.

Laudo Pericial do revólver “Taurus”, apreendido com o réu, a fls. 108/113.

Laudo Pericial da pistola “Glock”, da Polícia Militar, apreendida nos autos, a fls. 114/118.

Laudo Pericial do local dos fatos, a fls. 176/182.

Comprovante de depósito do valor apreendido (R\$ 365,00), a fls. 87.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23, Laudo de Constatação de fls. 24/27 e Laudo Pericial de fls. 277/279, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha e cocaína.

Quanto à conduta classificada pelo Ministério Público como apta a configurar o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, verifico que sua materialidade se encontra comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e do Laudo Pericial, referentes aos exames realizados, às fls. 108/113.

Não obstante, conforme se verá à frente, ressalvado o r. entendimento da nobre Promotora de Justiça subscritora da Denúncia, considero que o fato melhor se amolda à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em homenagem ao princípio da especialidade, não podendo, ainda, configurar também a infração contida na Lei nº 10.826/03, sob pena de bis in idem.

A autoria do crime acima, de tráfico, imputado ao acionado, ecoa da prova produzida, sem margem para a pretendida absolvição ou desclassificação.

No que tange, porém, ao crime de associação para o tráfico, respeitadas posições divergentes, melhor sorte não assiste à acusação.

O acusado não foi interrogado na etapa policial, em razão de ter sido internado em hospital para a realização de procedimento cirúrgico, por decorrência dos fatos.

Em audiência judicial, o réu GUSTAVO MARTINS alegou que, na data em questão, dirigiu-se ao local dos fatos para comprar drogas. No palco dos eventos, havia outro indivíduo, que também se encontrava ali para comprar entorpecentes, o qual avistou a aproximação da viatura da Polícia, motivo pelo qual gritou, sendo que o réu e outras pessoas ingressaram em uma viela próxima. Disse o acusado que reside

ali. Alegou ter ido de encontro ao policial, porém, não possuía consigo qualquer droga. Relatou que ao ser abordado pelos policiais, levantou as mãos, conforme ordenado e se virou de costas e de frente. Não obstante, o policial gritou para que largasse a arma, ao que respondeu não possuir nenhuma arma, tendo o agente da lei, na sequência efetuado um disparo de arma de fogo contra o réu. O réu relatou ter sofrido um desmaio e se recorda apenas até este momento. Após alguns dias, acordou já no hospital. Ainda relatou que, quando recobrou a consciência, o policial que efetuou o disparo compareceu ao hospital e perguntou ao réu se ele "era do partido", tendo o acusado respondido negativamente. O policial ainda perguntou se o acionado iria assumir a posse das drogas, tendo este respondido que estava no local apenas para comprar entorpecentes. Relatou, na sequência, que, na ocasião narrada, havia cerca de oito a dez policiais no quarto do hospital, todos perguntando se ele "era do partido". Indagado, negou que estivesse com uma arma ou com drogas, na ocasião dos fatos. Não portava pochete, igualmente. Possuía apenas oitenta reais, referente ao troco que recebeu do traficante, em razão da compra dos entorpecentes. Indagado, respondeu que não conhecia os policiais e nem o outro usuário que estava no mesmo local, quando foi comprar drogas. Porém, já conhecia o traficante. Na viela, onde foi alvejado, havia alguns populares, residentes no local. Disse que, quando a Polícia chegou, correu por ter passagem criminal.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir. Triste investida!

Doutro lado, são os relatos firmes e harmônicos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão do réu.

Ouvindo em Juízo, o policial militar Bruno Felipe Tavares dos Santos relatou que ele e seu parceiro realizavam patrulhamento pela área dos fatos, já conhecido ponto de criminalidade, juntamente com outras equipes policiais, tendo por estratégia a entrada por diferentes locais. Neste sentido, disse que o réu fugia de uma das equipes policiais, tendo abandonado uma mochila com entorpecentes, momento em que se deparou com o depoente e apontou uma arma de fogo contra este, motivo pelo qual o ora declarante efetuou um disparo contra o agente. Especificou que o réu corria ao encontro do depoente, eis que encontrava-se fugindo de outros policiais, já com a arma em punho, entretanto, não chegou a efetuar nenhum disparo contra o declarante, não sabendo este dizer se a arma falhou ou se o agente chegou a tentar acioná-la. Relatou que em poder direto do réu estava uma pochete, no interior da qual havia certa quantidade de entorpecentes e de dinheiro. Quanto à mochila, na qual havia cerca de seis quilos de maconha, segundo se recorda, esta foi abandonada pelo réu no local onde se encontrava assim que visualizou a primeira equipe da Polícia. Indagado, respondeu que no local havia outro indivíduo, além do réu, que, contudo não foi preso. Questionado, disse que na mochila havia maconha e na pochete que o réu trazia consigo, havia drogas diversas, recordando-se de maconha e cocaína, além de dinheiro. À defesa, respondeu que, quando o réu o avistou, ele já mirou no depoente. Disse que, na viela, estava a pé, na companhia de seu parceiro de equipe, que se encontrava atrás. Acerca da mochila localizada, relatou que não visualizou o réu em posse desta, posto que, neste momento, ingressava na comunidade por outra entrada. Também à defesa, respondeu que, no local onde o réu foi visto inicialmente, por outra equipe policial, havia mais indivíduos ao seu lado, porém, no momento em que o depoente se deparou com o acusado, que estava em fuga, o agente estava sozinho, de modo que, no local somente se encontravam o réu, o depoente e o parceiro de equipe deste. Negou, por fim, ter comparecido ao hospital onde o réu ficou internado após os fatos.

Na sequência, foi ouvido o policial militar Valdir Araújo de Oliveira, declarando que estava presente quando efetuada a prisão do réu. Relatou que efetuavam patrulhamento na Favela Jaqueline, local já conhecido pelo tráfico de drogas, havendo mais de uma equipe policial presente. Uma das equipes entrou por um dos lados da viela existente no local, enquanto a equipe do depoente e seu parceiro ingressou pelo outro, a fim de evitar eventual fuga de suspeitos. A primeira equipe

se deparou com dois indivíduos na ponta da viela, os quais fugiram, tendo um deles abandonado uma mochila neste momento. A equipe do declarante, que ingressava pela outra ponta, então, se deparou com um dos dois suspeitos, o qual vinha ao seu encontro com uma pochete a tira colo e uma arma em punho. Neste momento, tal indivíduo apontou a arma que trazia consigo contra os policiais, motivo pelo qual o parceiro do declarante atirou nele antes. Indagado, respondeu que na mochila abandonada pelo réu havia milhares de porções de maconha e, na pochete que este trazia consigo, um número menor de drogas, dentre porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie. Respondeu que, na viela, no momento em que se depararam com o acusado, só estavam ali este, o depoente e seu parceiro. Declarou, categoricamente, que o réu portava a arma de fogo apreendida. À defesa, detalhou que ele e seu parceiro ingressaram na viela a pé, sendo que estava atrás deste. Relatou que seu parceiro efetuou dois disparos com a arma de fogo. Acerca da mochila abandonada pelo réu, confirmou que não visualizou este fato, que somente chegou ao seu conhecimento pelos policiais da outra equipe.

É a prova oral.

No quadro acima, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo drogas, consistentes em 39,3g de cocaína, subdivididas em 167 porções, e 69,9g de maconha, em 19 porções individuais e prontas para uso (drogas estas que se encontravam no interior da pochete que o acionado trazia consigo quando foi preso), marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente porque não demonstrou qualquer condição econômica para possuir tamanha quantidade de drogas para consumo pessoal, sequer comprovando emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Entretanto, no que concerne às quase quatro mil porções de maconha localizadas na mochila apreendida, inviável o reconhecimento seguro de que pertenciam ou estavam na posse do acusado, ainda que de forma mediata.

Isso porque, sem retirar o crédito das palavras das testemunhas policiais, ambos declararam que não viram o momento em que o réu teria abandonado a tal mochila, na medida em que ingressaram pela outra ponta da viela, surpreendendo o acusado apenas em posse da pochete e arma de fogo.

Narraram, então, que ficaram sabendo que a outra equipe visualizou o réu na posse da mochila, o que, respeitados entendimentos contrários, não basta para se imputar ao acusado a posse destas drogas, à mingua de provas mais robustas que autorizassem tal conclusão.

Se outra equipe presenciou cena relevante, seus componentes deveriam ter sido identificados e ouvidos, pena de subtração de prova em contraditório, algo que arranha a presunção de inocência, e o princípio da legalidade.

Assim, recai sobre o réu unicamente a posse dos entorpecentes encontrados na pochete que carregava.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas com o réu, num total de 186 (cento e oitenta e seis) porções de entorpecentes variados, incluindo cocaína, altamente lesiva, a forma de acondicionamento das drogas, embaladas em porções individuais, prontas para a venda no "varejo", as circunstâncias do flagrante, tendo o réu sido surpreendido enquanto fugia da Polícia, carregando consigo uma arma de fogo em mãos, além de uma pochete onde localizados os entorpecentes, a localização de considerável quantia em dinheiro em espécie com o acionado, no total de R\$ 365,00, os depoimentos firmes dos policiais que o abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o acusado efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

Com efeito, é irrelevante a não identificação precisa do(s) cliente(s) do comércio espúrio, pois a prática do crime de tráfico de drogas independe da efetiva venda dos entorpecentes, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "trazer consigo" os entorpecentes.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público quanto ao crime de tráfico de drogas, imputado em desfavor do acionado, sendo inviável a pretensão desclassificatória pretendia pela Defesa, na medida em que o acionado era efetivo mercador, e não mero colaborador. E, neste sentido, considero que a imputação da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, a bem da verdade, melhor se amolda à causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Digno de nota que não está o juiz vinculado à definição jurídica dada pela acusação quando do oferecimento da Denúncia, conforme se extrai do art. 383 do Código de Processo Penal, certo que o réu se defende dos fatos, estes que, portanto, delimitam o objeto da demanda e impedem que o magistrado se manifeste a respeito daquilo que não foi descrito na petição inaugural, em homenagem ao princípio da adstrição ou congruência.

Prosseguindo, há nos autos prova da materialidade, decorrente do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e do Laudo Pericial do revólver "Taurus", apreendido com o réu, a fls. 108/113, bem certeza da autoria.

Conforme bem narraram ambas as testemunhas policiais, ao realizarem a incursão pela outra ponta da viela, se depararam com o acusado, que vinha em direção dos policiais, fugindo da outra equipe que o havia surpreendido instantes antes. Neste momento, o réu portava uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, com a qual, inclusive, chegou a apontar para os policiais ora ouvidos na qualidade de testemunhas, o que motivou a realização de um disparo por parte do policial militar Bruno Felipe, em legítima defesa.

Reafirmo que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo perverso, tivessem a intenção de acusar falsamente o réu, mormente "plantando" uma arma de fogo no local dos fatos, com a finalidade única de incriminar o acusado e, pior, alvejando-o a fim de corroborar eventual narrativa inventada.

Neste sentido, a versão defensiva restou absolutamente isolada nos autos, desamparada por quaisquer provas que pudessem elidir as declarações dos policiais.

Chamo atenção, no ponto, para o fato de que o réu, em interrogatório judicial, afirmou que, na viela, havia alguns populares, residentes na comunidade.

Entretanto, não arrolou nenhuma testemunha capaz de afiançar a sua versão.

Por fim, o próprio réu também declarou em interrogatório que não conhecia os policiais que o prenderam, o que reforça a isenção destes e, portanto, as versões dos fatos por eles prestadas sob o crivo do contraditório.

Desta forma, da prova se extrai que o acusado, de fato, portava arma de fogo de uso permitido, o que fazia no contexto do crime anteriormente avaliado, ou seja, de tráfico de drogas.

Com efeito, as circunstâncias fáticas em que empregado o armamento estão absolutamente vinculadas à atividade de mercancia espúria dos entorpecentes, remetendo-se, pelo princípio da especialidade, à majorante descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva; (destaquei)

Assim, não há se falar em conduta autônoma de portar arma de fogo, em tendo sido esta empregada de maneira ostensiva na atividade de traficância desenvolvida pelo réu, inclusive como maneira de buscar se esquivar da abordagem policial e garantir sua pretendida impunidade.

Neste sentido, colaciono os julgados abaixo, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA BEM DELINEADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO PELO ARTIGO 37 DA LEI DE TÓXICOS, VEZ QUE NÃO SE TRATA DE MERO INFORMANTE – DOSIMETRIA PENAL REFORMADA –

ABSORÇÃO DOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR CAUSAS DE AUMENTO ESPECÍFICAS ARROLADAS PELO ARTIGO 40, INCISO IV E VI, DA LEI 11.343/2006 - LEGITIMIDADE DO REGIME FECHADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PARA ANÁLISE DA DETRAÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença condenatória.

1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelos dois delitos. Materialidade e autoria comprovadas.
2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.
3. Estado de necessidade não configurado.
4. No tocante ao porte ilegal de arma de fogo, diante das circunstâncias do caso, a conduta não configura delito autônomo, qualificando-se como causa de aumento de pena do delito de tráfico de drogas (artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06), eis que evidenciada, de forma clara, a utilização da arma de fogo para viabilizar, através da intimidação, o comércio de drogas. Hipótese de concurso aparente de normas, com aplicação da regra da especialidade.
5. Penas redimensionadas. Recurso parcialmente provido.

(...)

Com efeito, "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas, exige-se o nexó finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico" (STJ. HC nº 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Onde, bem decretada a condenação em primeiro grau.

Destarte, no caso em tela, em que o contexto demonstra o vínculo entre o porte da arma de fogo e a prática do tráfico de drogas, de rigor a absorção daquele crime por este, configurando-se, contudo, a causa de aumento de penas prevista na Lei de Tóxicos, a ser valorada na oportuna etapa da fixação das reprimendas do acusado. Finalmente, no que tange à acusação pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 35 da Lei nº 11.343/06), respeitados entendimentos divergentes, a meu ver a acusação não se confirmou.

No ponto, a prova se mostra tímida e insuficiente a demonstrar, com significativa certeza moral, que o acionado tenha, efetivamente, se associado a outrem para a prática do delito de tráfico de drogas, a tanto não bastando mera inferência, na denúncia, de que assim ele agiu, ausente, consoante a prova, real indicação de estabilidade e permanência da afirmada societas sceleris, de forma duradoura, de molde a permitir a ideia do ânimo associativo.

Vale destacar que, no caso em apreço, sequer a identidade da pessoa com que o réu teria se associado foi descoberta, o que demonstra a precariedade da acusação neste ponto.

Portanto, acerca de tal acusação, a absolvição se mostra do mais absoluto rigor.

Sobre o tema, confirma-se: Apelação nº 0016441-16.2009.8.26.0269, rel.

Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0000973-88.2013.8.26.0360, rel.

Desembargador Francisco Orlando; Apelação nº 0004370-17.2012.8.26.0482, rel.

Desembargador Péricles Piza; Apelação nº 0001975-20.2008.8.26.0150, rel.

Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 0044365-36.2010.8.26.0602, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 0092049-

27.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Ericson Maranhão; Apelação nº 0019147-

16.2012.8.26.0576, rel. Desembargador Almeida Sampaio; Apelação nº 0008704-

73.2012.8.26.0586, rel. Desembargador Encinas Manfré; Apelação nº 0018331-

56.2012.8.26.0019, rel. Desembargador Paulo Rossi; Apelação nº 0007731-

25.2009.8.26.0360, rel. Desembargador Ivo de Almeida; Apelação nº 0001387-

42.2011.8.26.0268, rel. Desembargador Ivan Marques; Apelação nº 0012269-96.2010.8.26.0624, rel. Desembargador Silmar Fernandes; Apelação nº 0916762-38.2012.8.26.0037, rel. Desembargador Mário Devienne Ferraz; Apelação nº 0002566-02.2011.8.26.0368, rel. Desembargador Fernando Simão; Apelação nº 0002647-32.2011.8.26.0438, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0114249-91.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Solimene.

Outro não se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus nº 273.749-RS, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Habeas Corpus nº 248.090-SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Habeas Corpus nº 254.558-SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Habeas Corpus nº 166.979-SP, rel. Ministro Jorge Mussi; Habeas Corpus nº 193.232-SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; Habeas Corpus nº 120.343-GO, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz; Habeas Corpus nº 271.723-MG, rel. Ministro Marco Aurélio Belizze; Habeas Corpus nº 248.844-GO, rel. Ministra Laurita Vaz.

Bem firmadas as responsabilidades dos réus, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis, dada a especial reprovabilidade da conduta do acusado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas, num total de 186 (cento e oitenta e seis) porções de entorpecentes variados, dentre os quais destaco a cocaína, altamente lesiva. Assim, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo as penas base em patamar 1/6 superior ao mínimo, estabelecendo o cumprimento da pena corporal de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos e oitenta e três dias multa.

Em segunda fase, verifico, a presença de duas circunstâncias agravantes.

Inicialmente, cuida-se de acusado reincidente, conforme certidão de fls. 39/41, condenado em definitivo pela prática do crime de roubo, pelo qual, segundo consta, se encontrava em livramento condicional quando da prática delitiva ora apurada. Não bastasse, resta presente também a circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (24.06.2021), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esta que, necessário consignar é de natureza objetiva, consoante leciona a doutrina: As circunstâncias agravantes genéricas são de caráter pessoal ou subjetivas, quanto: a) ao móbil do injusto ou à finalidade de agir (v.g.: motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação ou impunidade ou vantagem de outro injusto, ou por motivo de lucro); b) a qualidade ou condição pessoal do agente (embriaguez preordenada, com abuso do poder ou abuso de autoridade); c) quanto às relações do autor do ato com o sujeito passivo ou com os outros partícipes (parentesco, relações domésticas, de coabitação, ou hospitalidade; promovendo, organizando a cooperação ou dirigindo a atividade criminosa; instigando, coagindo a execução delitiva). Já as circunstâncias agravantes genéricas são de caráter objetivo, quanto: a) aos meios e modos de execução (traição, emboscada, dissimulação, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura); ao tempo e lugar (por ocasião de incêndio, naufrágio, calamidade pública); c) à pessoa ou à condição da vítima (criança, velho, enfermo, pessoa sob estado de desgraça particular, ou pessoa sob imediata proteção da autoridade. (página 405, Direito Penal, Parte Geral, volume 3, 7ª edição, Álvaro Mayrink da Costa); O agente não cria, como na letra d, mas aproveita os efeitos da calamidade pública (além dos exemplos legais: seca, epidemia, guerra, extrema e geral carestia da vida, invasão armada, insurreição, certas greves, etc.) que, por natureza, atinge a coletividade, ou de calamidade particular (acidente, falência, infortúnios domésticos e pessoais em geral, etc.). Em todos os casos, a maior periculosidade define-se pela falta dos requisitos primários da solidariedade humana, pela completa ausência de senso moral. O agente não só desatende a imperativos éticos rudimentares, como não se detém diante dos supremos espetáculos da dor e do perigo, e ainda encontra neles sugestões e estímulos para aumentar a aflição dos aflitos. (página 299, Comentários ao Código Penal, volume 2, 2ª edição, Roberto Lyra); Situações de calamidade pública, como incêndios, inundações, ou mesmo naufrágios, ou de desgraça particular, como acidentes de trânsito, representam condições

concretas adversas que reduzem ou excluem a capacidade de proteção pessoal ou patrimonial das vítimas, aumentando a reprovabilidade das ações lesivas de bem jurídicos penalmente protegidos. (página 578, Direito Penal, Parte Geral, 2ª edição, Juarez Cirino dos Santos)

Bem por isso, então, respeitado sempre o entendimento da Defesa, não reclama qualquer nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, máxime porque acerca da edição da norma que decretou o estado de calamidade pública, advinda da autoridade competente a nível Federal e Estadual, não pode o acionado alegar inciência, pena de fazer letra morta do disposto no art. 3º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42), in verbis: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Neste cenário, elevo suas reprimendas em 1/5, fixando a pena de sete anos de reclusão e pagamento de valor equivalente a seiscentos e noventa e nove dias multa. Em terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, decorrente do emprego de arma de fogo no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, consoante anteriormente fundamentado.

Destarte, dada a maior reprovabilidade da conduta em análise, elevo as reprimendas do acusado no equivalente a 1/6, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 815 (oitocentos e quinze) dias multa, fixados estes no patamar unitário mínimo previsto em lei, penas estas que torno definitivas, na medida em que inexistem causas de diminuição de penas, sendo absolutamente inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em virtude da reincidência do acionado.

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena corporal aplicada no regime inicial fechado, em tendo sido a ele aplicada pena corporal superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a)", do Código Penal, bem como em se tratando de acusado reincidente.

Não fosse o bastante, ainda, a necessidade do regime mais rigoroso advém, ainda, do comando que emerge do art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90.

De todo inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, na medida em que o quantum da pena aplicada, muito superior a quatro anos, impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincidente que ostenta o réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP, sendo, no mais, absolutamente insuficiente e inadequada na hipótese em apreço.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e assim o faço para ABSOLVER o acusado GUSTAVO MARTINS da acusação pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para, de outro lado, CONDENAR o réu GUSTAVO MARTINS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 815 (oitocentos e quinze) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em

preventiva, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do acusado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido e depositado a fls. 87 dos autos (R\$ 365,00) ao FUNAD, posto que evidente produto do comércio espúrio. Arcará o sentenciado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC.
P.R.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06